

非法经营罪指的是违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。我国对出版物批发、零售依法实行许可制度。从事出版物批发、零售活动的单位和个人凭出版物经营许可证开展批发、零售活动；未经许可，任何单位和个人不得从事出版物批发、零售活动。任何单位和个人不得委托非出版物批发、零售单位和个人销售出版物或者代理出版物销售业务。本案中，被告人违反国家规定，未经许可在网络上非法从事出版物的销售活动，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。认定非法经营罪的个人非法经营图书的数量时，应注意扣除销售侵犯著作权图书以及其他非图书的商品的数量，符合《最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》之规定的情形之一的，以非法经营罪追究其刑事责任。根据《最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十一条的规定，违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉……非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务，严重扰乱市场秩序，具有下列情形之一的：(1)个人非法经营数额在15万元以上的，单位非法经营数额在50万元以上的；(2)个人违法所得数额在5万元以上的，单位违法所得数额在15万元以上的；(3)个人非法经营报纸1.5万份或者期刊1.5万本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的，单位非法经营报纸5万份或者期刊5万本或者图书

1.5万册或者音像制品、电子出版物5000张(盒)以上的；(4)虽未达到上述 数额标准，二年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过两次 以上行政处罚，又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。本案中， 两店铺实际销售其余图书的数量为3769册，金额为134763.69元。被告人供述 其个人违法所得约4万元。本案中，被告人未受过行政处罚，从个人非法经营 数额、违法所得、出版物数量上均未达到立案追诉标准。故，指控被告人犯非 法经营罪不能成立。

综上，个人以营利为目的，未经授权制售图书的行为构成侵犯著作权罪， 犯罪金额为鉴定报告中认定的侵权图书销售数量乘以销售金额。未经许可在网

络上销售其他图书的行为构成非法经营罪，非法经营的数额为扣除非图书类商品的数额。

编写人：河北省肃宁县人民法院 侯应心

单纯不正当获取商业秘密行为给权利人造成损失的认定

一 吕某某侵犯商业秘密案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省武汉市中级人民法院(2023)鄂01知刑终2号刑事裁定书

2. 案由：侵犯商业秘密罪

【基本案情】

某技术公司对超低衰减光纤制备、OVD（一种工艺）套管设备制造等技术进行研发，并对涉密的技术信息采取了一系列保护措施，包括在生产现场和研发实验区进行门禁权限管理，要求员工单独设置电子邮箱密码，保护内容不被泄露，禁止员工随意复制、扫描、打印、下载、拷贝技术秘密文件等。

2014年10月起，某技术公司聘任吕某某担任公司的技术顾问，主要提供技术方面的顾问服务，但不参与公司项目的经营、管理和技术的决策。2018年1月至2020年4月，吕某某推测出公司研发人员的电子邮箱账号密码后，多次在其家中异地登录他人邮箱并秘密下载邮件内资料，随后打印、拍摄上述资料并将邮件内容传输到个人笔记本电脑中存储。公安机关于2020年5月将吕某某抓获归案，在其笔记本电脑的恢复数据以及打印资料中查获涉及某技术公司“预处理工序”“0.16分贝/千米超低衰减光纤制备技术”“0.15分贝/千米超低衰减

光纤制备技术”“OVD 套管沉积芯棒设计图纸”“OVD 套管烧结芯棒设计图纸”五项不为公众所知悉的技术信息。案发后，某技术公司紧急更换电子邮箱系统。

湖北省武汉市江岸区人民检察院以吕某某犯侵犯商业秘密罪向法院提起公诉，并提交受某技术公司委托而出具的两份评估报告，以证明上述技术秘密的虚拟许可使用费为2880万元，更换电子邮箱系统产生的补救费用经评估为276.39万元。湖北省武汉市江岸区人民法院对上述两份评估报告进行严格审查，扣除无票据对应以及与技术秘密所涉项目无关的研制成本，采用成本法将涉案五项商业秘密的合理许可使用费调整为1086.81万元，并扣除邮箱验证人力费用中证据不足的部分，将更换邮箱的补救费用调整为268.10万元。

【案件焦点】

以不正当手段获取权利人的商业秘密，尚未披露、使用或者允许他人使用的，给权利人造成的损失数额如何认定。

【法院裁判要旨】

湖北省武汉市江岸区人民法院经审理认为：吕某某以盗窃的不正当手段获取权利人的商业秘密，给权利人造成的损失数额包括涉案技术秘密的合理许可使用费及更换邮箱的补救费用共计1354.91万元，上述行为造成特别严重后果，构成侵犯商业秘密罪。公诉机关指控吕某某犯侵犯商业秘密罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。吕某某虽未披露、使用或者允许他人使用其不当获取的商业秘密，但其行为侵犯了权利人对商业秘密的专有权利，破坏了公平竞争的社会主义市场经济秩序，造成特别严重后果，应受刑罚处罚。吕某某以不正当手段获取涉案商业秘密并未获利，其在获取商业秘密后亦未披露、使用或者允许他人使用，对其可以酌情从轻处罚。据此，以侵犯商业秘密罪判处被告人吕某某有期徒刑三年，并处罚金人民币50万元。

一审宣判后，吕某某提出上诉。

湖北省武汉市中级人民法院同意一审法院裁判意见，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(三)》的规定,以不正当手段获取权利人的商业秘密,尚未披露、使用或者允许他人使用的,给权利人造成的损失数额可以根据商业秘密的合理许可使用费确定。为减轻对商业运营、商业计划的损失或者重新恢复计算机信息系统安全、其他系统安全而支出的补救费用,应当计入损失。但判断许可使用费和补救费用是否“合理”仍是司法实践中的难点。商业秘密通常不会被许可给他人使用,通过评估方式确定虚拟许可使用费的情况较为常见,单纯不正当获取商业秘密行为的危害性相对弱于其他类型的犯罪行为,但评估得出的许可使用费较高,为保障罪责刑相适应,审查虚拟许可使用费的合理性尤为必要。而对于补救费用,则需要审查费用的产生是否合理且必要。

一、虚拟评估的许可使用费的合理性审查

第一,审查评估方法的合理性。确定知识产权资产价值的评估方法一般包括市场法、收益法和成本法。没有实际许可但有同类技术许可合同参照的,按照市场法评估较为合理。在没有同类技术许可合同参照的情况下,具体适用何种评估方法更合理与技术本身的特征相关。本案中,五项技术秘密尚未被许可使用,市场上亦缺乏类似技术公开交易的案例,难以适用市场法评估;涉案技术秘密所属的整体产线技术复杂,难以从中进行收益剥离,相较收益法采用成本法评估涉案技术秘密的许可费用更具合理性。第二,审查商业秘密和取价依据的关联性。本案采用成本法进行评估的取价依据应是某技术公司在具体项目中的研发费用支出统计数据、明细账、发票等。经审查发现,部分秘密点的取价依据不属于技术秘密所涉项目,对此部分法院予以扣除。第三,审查取价依据的原始凭证。本案中,鉴定人在评估过程中仅抽取部分取价依据进行核查后推断全部取价依据无误,法院重新审核全部取价依据的原始凭证和相关财务资料,扣除无票据对应的研制成本,采用成本法对涉案五项商业秘密的合理许可使用费进行调整。

二、补救费用的合理性审查

补救费用是指权利人为避免损失扩大而支出的费用，可以与其他损失合并计入总的损失数额。以补救费用计算损失时，需要审查该费用是否为避免损失所必要，补救措施应对损失的避免起到有效的作用，如果商业秘密因侵权行为已为公众所知悉或者灭失的，不具有补救的可能，不宜将相关补救措施的支出计入损失。还需要审查该费用本身是否合理，如果以较小的补救成本就可以避免损失，而权利人采取过激补救措施，付出过高的补救费用，对于超出合理性的费用不宜计入损失。本案中，某技术公司更换后的邮箱系统安全性能更高，能有效避免擅自异地登录他人邮箱行为的发生，该补救措施具有必要性，可以以更换电子邮箱的合理补救费用确定损失数额。更换电子邮箱过程中不仅会产生设备费用，还会产生验证、排查等人力费用，也应视为补救费用的一部分，但人力费用的计算应以工资成本为依据，对于没有证据对应的人力费用法院不予支持。

编写人：湖北省武汉市江岸区人民法院
杨敬文

符合一定特征的经营信息可以认定为商业秘密

—— 王某侵犯商业秘密案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

2. 案由：侵犯商业秘密罪

【基本案情】

被告人王某在某体育器材公司工作期间，基于职务行为，掌握了为某体育

器材公司所有的客户名单、交易习惯、客户需求、付款方式、供销渠道等不为公众所知悉的经营信息。2019年4月5日，被告人王某告知某公司业务联系人李某，其将从某体育器材公司离职创业做同类产品。2019年4月9日，被告人王某告知某1公司业务联系人赵某，其将从某体育器材公司离职并从事健身系列方面的业务。2019年4月19日，被告人王某从某体育器材公司离职，离职前将保存在公司分配给其使用的办公电脑中的某体育器材公司与5家外商客户(其中包括某公司、某2公司、某1公司)交易的资料拷贝至其私人移动硬盘，资料内容包含对应外商客户与某体育器材公司的外贸订单、产品式样、产品价格、供应商采购合同、报关数据等。2019年5月27日，某体育器材公司通知被告人王某于5月31日到公司领取竞业限制补偿费，并告知逾期未领取并不免除竞业限制义务。因王某未如期到公司领取，某体育器材公司于同年6月1日将4月、5月的竞业限制补偿费转账至王某原在某体育器材公司的工资账户内，王某于同日尽数退回。

2019年4月16日，运动科技公司法定代表人为邵某，实际由王某负责经营。运动科技公司的经营范围包括健身器材、运动用品的研发、设计、销售、进出口业务等。被告人王某从某体育器材公司离职后，违反与某体育器材公司签订的保密协议、竞业限制协议等，使用所掌握的某体育器材公司的客户信息等商业秘密，以运动科技公司的名义与某体育器材公司客户某公司、某2公司、某1公司开展健身用品、体育用品的外贸出口业务。从2019年5月7日起开始分别与某公司、某2公司、某1公司发生账款往来。2019年6月至2020年12月，向某公司出口18次，出口金额495394.23美元；2019年7月27日向某2公司出口1次，出口金额3290美元；2020年11月23日向某1公司出口1次，出口金额28787.83美元。而从某体育器材公司所发生的外贸交易情况来看，经专项审计，2019年5月至2020年9月，某体育器材公司出口至某1公司的销售利润同比2016年7月至2019年4月减少人民币482222.59元，出口至某2公司的销售利润减少人民币139476.06元，该时段内与某公司未发生新的出口贸易。

【案件焦点】

被告人在某体育器材公司工作期间掌握的客户信息是否属于商业秘密。

【法院裁判要旨】

江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区人民法院经审理认为：被告人在某体育器材公司工作期间掌握的客户信息满足不为公众所知悉、具有较大的经济价值及采取了相应的保密措施等三个要件，属于我国反不正当竞争法规定的商业秘密。被告人王某违反约定和权利人有关保守商业秘密的要求，使用其所掌握的商业秘密，给商业秘密权利人造成重大损失，其行为触犯1997年《中华人民共和国刑法》第二百一十九条第一款第三项规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯商业秘密罪追究其刑事责任。被告人王某犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。依照1997年《中华人民共和国刑法》第二百一十九条第一款第三项，《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》第四条、第五条、第十条、第十一条、第十二条之规定，作出如下判决：

被告人王某犯侵犯商业秘密罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币30万元。

一审宣判后，被告人王某提出上诉。

江苏省南通市中级人民法院经审理认为：一审法院判决认定上诉人王某犯侵犯商业秘密罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

随着市场竞争日益激烈，有关客户信息引起的纠纷逐渐增多，在外贸、咨询、培训、市场调研等行业尤为突出，所引发的案件逐年增多。此类案件多因员

工跳槽引起，涉及原单位与前员工、新单位的客户选择自由及社会公共利益的合理平衡，审理难度较大。同时，客户信息往往是部分公知信息与特有信息的结合体，市场和客户的不断变化又导致其内容难以确定，加之侵犯商业秘密罪案件数量很少，司法实务中，客户信息是否构成商业秘密，成为审理中的焦点和难点。

客户信息构成商业秘密须满足三个要件。《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第四款规定，商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第一条第三款规定，客户信息包括客户的名称、地址、联系方式以及交易习惯、意向、内容等信息。对于商业秘密的构成要件，通说认为客户信息构成商业秘密需要具备三个要件：秘密性、保密性、价值性。

首先，关于秘密性要件，即不为公众所知悉的条件。当事人常以被诉客户信息为公知信息或者属于行业惯例作为辩解。笔者认为，判定是否符合秘密性要件，可从客户信息有无足够的深度、权利人是否投入人财物、其他竞争者正当获取客户信息的难易程度来判断。案涉客户信息不仅包括公知领域中的客户名称，还包括客户在产品需求、产品价格、付款方式、交易习惯等方面的深度信息，体现于双方的联络及长期稳定的交易中，行业内其他经营者不经过努力，很难在公开领域直接获得，符合秘密性要件。虽然客户名称和联系方式可通过公开渠道查询，但互联网等公知领域中并不能获取属于商业秘密范畴内的产品需求、产品价格、付款方式、交易习惯等特殊信息，不能以客户名称、联系方式可以公开查询到就否定综合性客户信息的秘密性。

其次，关于价值性要件，即是否具有商业价值。当事人经常辩解客户信息本身并无价值，客户选择合作对象更多考虑对方的服务和业务能力。这就需要着重分析客户信息反映出的产品需求、交易习惯、产品价格等内容，是否有利于企业有针对性地向客户达成交易，是否已与客户形成长期相对稳定的交易，是否能够或者已经为公司带来竞争优势和经济利益，以此来综合评判。商业价值包括现实的或者潜在的商业价值。故，判断是否具备价值性要件时，不能以

